

사이닝보너스 반환약정의 유효성에 관한 연구

권 오 성*

- I. 들어가며
- II. 강제근로의 금지 및 위약예정 금지의 입법취지와
그 현대적 의미
- III. 사이닝보너스 반환약정의 유효성에 관한 검토
- IV. 맺는 말

〈 국문초록 〉

사이닝보너스(Signing bonus)란 일반적으로 우수한 인재를 채용하기 위하여 기업이 근로자와 근로계약을 체결함과 동시에 근로자에게 일시불로 지급하는 금원으로 이해되고 있다. 이러한 사이닝보너스는 미국의 프로스포츠 선수들이 전속계약금 조로 지급받는 금원에서 유래한 것인데, 고용의 유연화 경향에 따라 경력직 직원의 이동이 활발해지자 일반 기업에서도 우수한 인력을 스카우트하기 위한 방법으로 유사한 제도를 도입한 것으로 알려지고 있다. 우리나라의 경우에도 1990년대 말부터 대기업들을 중심으로 사이닝보너스를 지급하는 사례가 늘고 있다. 그런데 기업이 이러한 사이닝보너스를 지급하는 경우에는 사이닝보너스를 지급하는 대가로 근로자에게 일정한 기간을 의무적으로 근무할 것을 요구하는 것이 일반적이며, 나

* 성신여자대학교 법과대학 부교수, 변호사.

가 근로자가 이러한 의무근무기간을 위반할 경우에는 기업으로부터 수령한 사이닝보너스의 전부 또는 일부를 반환하는 조건으로 하는 경우가 일반적이다. 이러한 사이닝보너스 반환약정은 의무근무기간과 결합하여 근로자의 자유의사를 제한하는 결과를 초래할 수 있다는 점에서 근로기준법 제7조 및 동법 제20조와 관련하여 사이닝보너스 반환약정의 유효성이 문제가 되고 있다.

필자는 본고에서 사이닝보너스 반환약정의 유효성에 관한 판단기준을 모색하기 위하여 먼저 근로기준법 제7조 및 제20조의 입법취지를 살펴보고, 이를 통하여 강제근로 금지 및 그 구체적인 실천수단으로 입법된 위약예정 금지의 전통적인 의미와 이들 제도의 현대적인 의미를 살펴보고, 이를 기초로 근로기준법 제7조 및 제20조의 적용범위와 그 한계를 검토한 후, 사이닝보너스 반환약정의 유효성의 판단을 위한 합리적인 해석기준을 모색하고자 한다. 구체적으로 사이닝보너스 반환약정의 유효성은 기업이 근로자에게 사이닝보너스를 지급하게 된 제반경위와 지급약정의 제반조건을 종합적으로 고찰하여 먼저 (i) 당해 반환약정이 근로기준법이 금지하는 위약금 또는 손해배상액의 예정으로 인정되는 경우에는 당해 반환약정 전부를 무효로 하고, (ii) 당해 반환약정이 위약금 또는 손해배상액의 예정에 해당하지 않는 경우에는 기업이 지급한 사이닝보너스의 임금성을 검토하여 사이닝보너스가 의무근무기간의 근로에 대한 선급임금의 성격을 갖는다면 퇴사시점까지 기근로한 부분에 관한 임금부분을 공제한 나머지 부분에 대해서만 반환청구를 인정하는 것이 사이닝보너스 반환약정의 합리적인 해석방법이라고 생각된다.

I. 들어가며

사이닝보너스(Signing bonus)란 일반적으로 우수한 인재를 채용하기 위하여 기업이 근로자와 근로계약을 체결함과 동시에 근로자에

게 일시불로 지급하는 금원으로 이해되고 있다. 이러한 사이닝보너스는 미국의 프로스포츠 선수들이 전속계약금 조로 지급받는 금원에서 유래한 것인데, 고용의 유연화 경향에 따라 경력직 직원의 이동이 활발해지자 일반 기업에서도 우수한 인력을 스카우트하기 위한 방법으로 유사한 제도를 도입한 것으로 알려지고 있다. 우리나라의 경우에도 1990년대 말부터 대기업들을 중심으로 사이닝보너스를 지급하는 사례가 늘고 있다.¹⁾ 기업이 사이닝보너스를 지급하는 동기로서는 경력직 직원의 이직에 대한 보상 차원으로 지급하는 경우도 있고, 입사예정자에 대한 예우의 차원에서 지급하는 경우도 있는 것 같다. 어떠한 경우이든 사이닝보너스의 지급에 있어서는 이를 수령하는 대가로 근로자에게 일정한 기간을 의무적으로 근무할 것을 요구하는 경우가 많으며, 이러한 의무근무기간을 위반할 경우에는 사이닝보너스의 전부 또는 일부를 반환하기로 약정하는 경우가 많다.

이러한 사이닝보너스의 지급과 관련하여서는 사이닝보너스가 근로기준법상 임금에 해당하는지 여부(구체적으로는 평균임금을 산정함에 있어 사이닝보너스를 임금총액에 포함하여야 하는지 여부), 사이닝보너스에 관한 과세와 관련하여 이를 어떠한 소득으로 인식해야 하는지 등이 실무상 문제가 되어 왔으며,²⁾ 노동법적인 관점에서는 사이닝보너스의 반환약정의 유효성이 중요한 법적 쟁점으로 대두되고 있다. 즉 사이닝보너스 반환약정이 의무근무기간과 결합하여 근로자의 자유의사를 제한하는 결과를 초래할 수 있다는 점에서 사이

1) 1999. 7. 5.자 연합뉴스에 의하면 LG전자는 핵심 전문인력 확보를 위해 우수인재 입사때 상한선 없이 일시불로 지급하는 사이닝보너스(Signing Bonus)제를 실시한다고 발표하였다. <<http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004404357>> (2012. 2. 11. 방문) 참조.

2) 참고로, 회사가 근로계약 체결시 입사에 전지급하는 사이닝보너스를 근로소득으로 볼 것인지 아니면 일시적이고 우발적인 성격의 기타소득으로 볼 것인지의 여부에 관하여 국세청은 종래 이를 '사례금'으로 보아 기타소득으로 과세하는 경향에 있었으나(서일 46011-10272, 2001. 10. 6. 등), 2000년대 중반부터 태도를 바꾸어 일정요건의 근로계약(약정 근로기간 미근무시 반환조건)을 체결하고 당해 계약에 따라 지급받는 사이닝보너스는 근로소득에 해당한다는 입장을 취하고 있다(서면2팀-1738, 2006. 9. 19. 및 서면1팀-402, 2006. 3. 29).

닝보너스 반환약정이 근로기준법(2012. 2. 1, 일부개정 법률 제11270호) 제7조의 강제근로의 금지 조항 내지 동법 제20조의 위약 예정의 금지 조항에 위반하는지가 해석상 문제되고 있다. 이러한 문제점에도 불구하고 우리나라에는 아직까지 사이닝보너스 반환약정의 유효성에 관한 깊이 있는 연구가 이루어지지 않고 있는 상황인바, 본고에서는 사이닝보너스 반환약정의 유효성과 관련하여 직접적으로 문제가 되는 근로기준법 제7조 및 동법 제20조의 입법취지와 이들 제도의 현대적인 의미를 살펴보고, 이를 바탕으로 근로기준법 제7조 및 동법 제20조의 적용범위와 그 한계를 검토한 후, 이러한 논의를 토대로 사이닝보너스 반환약정의 유효성을 판단하기 위한 합리적인 해석기준을 모색해 보고자 한다.

II. 강제근로의 금지 및 위약예정 금지의 입법취지와 그 현대적 의미

1. 강제근로 금지의 원칙의 전개

인류의 역사를 통해 보면 고대의 노예제도나 중세의 농노, 근대의 각종 형태의 노예제도, 유형지에서의 강제노동이나 인신매매 등 다양한 형태의 강제노역이 이루어졌던 것은 부정할 수 없는 사실이며, 이러한 다양한 형태의 강제노역이 문서로써 폐지된 것이 그리 오래되지 않았다는 것 또한 분명한 사실이다. 예컨대, 영국에서 노예제 폐지법³⁾이 제정된 것이 1833년이며, 제정 러시아의 알렉산드르 2세가 농노 해방령(농노종속에서 벗어나는 농민에 관한 법)⁴⁾을 통하여

3) An Act for the Abolition of Slavery throughout the British Colonies; for promoting the industry of the manumitted Slaves; and for compensating the Persons hitherto entitled to the Services of such Slaves[1833. 8. 28.]

4) Polozheniya o Krestyanakh Vykhodyashchikh iz Krepostnoy Zavisimosti[1861. 3. 3.]

제정 러시아의 농민을 농노적 지위에서 해방한 것이 1861년이고, Abraham Lincoln의 노예해방선언(Emancipation Proclamation)으로 미국의 흑인노예가 해방된 것이 1863년이다. 이와 같이 모든 인간이 신분적 구속에서 벗어나 자발적인 노동을 통하여 생존을 영위할 권리를 가지게 된 것은 인류의 유구한 역사에 비추어 매우 짧은 기간에 불과하다. 이러한 점을 고려할 때 인간의 존엄성을 침해하는 강제근로로 부터 국민을 보호하는 것은 국가의 기본적인 의무라고 할 것이다.

한편 근대국가의 헌법 중에서 ‘강제노역의 금지’에 관한 명문의 규정을 둔 입법례로는 ‘노예 또는 강제노역은 당사자가 정당하게 유죄 판결을 받은 범죄에 대한 처벌이 아니면 합중국 또는 그 관할에 속하는 어느 장소에서도 존재할 수 없다.’라는 조항을 명문화한 미국연방헌법 수정조항 제13조 제1절이 대표적이다.⁵⁾ 이는 1863년의 노예해방선언을 성문화한 것으로 동조항의 직접적인 취지는 흑인노예제를 폐지하는데 있었다. 한편, 강제근로 금지에 관한 국제적 노력의 유의미한 결과로서는 국제노동기구(International Labor Organization)가 채택한 강제근로에 관한 제29호 협약(1930년)⁶⁾과 제105협약(1957년)⁷⁾이 있으나, 우리나라는 대체복무제 등 국내사정을 이유로 아직까지 이들 협약을 비준하지 못한 상태이다.⁸⁾ 이외에도 그 자체

5) AMENDMENTS TO THE UNITED STATES CONSTITUTION ARTICLE XIII, Section 1. "Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction."

6) ILO 홈페이지 : <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029> (2012. 2. 11. 방문) 참조.

7) ILO 홈페이지 : <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105> (2012. 2. 11. 방문) 참조.

8) 고용노동부 홈페이지 <<http://www.moel.go.kr/policyinfo/nations/view.jsp?cate=1&sec=2>> (2012. 2. 11. 방문). 참고로, 헌법재판소는 ‘강제노동의 폐지에 관한 국제노동기구(ILO)의 제105호 조약은 우리나라가 비준한 바가 없고, 헌법 제6조 제1항에서 말하는 일반적으로 승인된 국제법규로서 헌법적 효력을 갖는 것이라고 볼 만한 근거도 없다’고 판시한바 있다(헌재 1998. 7. 16. 97헌바23 결정).

로는 법적 구속력이 없기는 하지만 1948. 12. 10. 제3차 국제연합총회에서 채택된 세계인권선언(Universal Declaration of Human Rights)은 ‘어느 누구도 노예나 예속상태에 놓여 지지 아니한다. 모든 형태의 노예제도 및 노예매매는 금지된다.’라는 원칙을 선언하였다(제4조). 한편, 1949년 창설된 유럽평의회(Council of Europe)가 1950. 11. 4. 채택하여 1953. 9. 3.부터 발효한 유럽인권협약(Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) 제4조 제1항은 ‘어느 누구도 노예 또는 예속상태에 놓여 지지 아니한다.’고 규정하였고, 동조 제2항은 ‘어느 누구도 강제적 또는 의무적 노동을 하도록 요구되지 아니한다.’고 규정하여 노예제의 금지와 강제노동의 금지를 선언하였다. 2013. 2월 현재 47개의 국가가 유럽인권협약에 가입하고 있다.⁹⁾ 따라서, 현대국가에서 봉건적 신분제나 노예적 구속, 인신매매 등의 수단에 의한 강제근로가 엄격히 금지되고 있다는 점을 의문의 여지가 없다고 할 것이다.

이와 같이 서구에서의 강제근로의 금지가 주로 봉건적 신분제나 노예제의 폐지와 관련하여 전개된 것과는 달리 근대 일본 및 일본의 강점으로 인하여 그 영향 아래 있던 우리나라의 경우에는 19세기 말부터 20세기 초까지의 양국의 공업화 과정에서 널리 행하여지고 있던 특유한 전근대적인 고용관행과 관련하여 강제근로의 금지가 문제되었다는 점에서 서구의 인권선언과는 그 연혁에 있어 다소 차이를 보이고 있다.

2. 일본에서의 강제근로 금지 및 배상예정 금지의 입법경위

개항이후 1920년대까지 일본에서는 미성년자나 연약한 여성들이

9) 유럽평의회 홈페이지 : <<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=8&DF=14/02/2013&CL=ENG>> (2012. 2. 11. 방문). 참고로, 조약의 국내적 시행에 특별한 실행조치를 요하는 영국에서는 유럽인권협약을 ‘인권법(Human Right Act, 1998)’로 제정하여 헌법적 효력을 부여하였다. 오승철, 「헌법이야기」, 서울: 태운당, 2011, 171면.

공장 노동자로서 가혹한 노동 조건과 열악한 환경에서 가혹한 노동에 시달리고 있었다.¹⁰⁾ 이 당시 일본에서는 홋카이도나 사할린의 공사 현장이나 탄광 노동자의 열악한 합숙소를 의미하는 ‘타코헤야(タコ部屋)’라는 단어가 상징하듯이 강제노동의 악습이 널리 행하여졌으며,¹¹⁾ 특히 섬유산업의 경우에는 여공들이 사용자와 고용계약을 체결하면서 사용자로부터 고액의 빚을 내고 그 임금으로 이를 변제하거나,¹²⁾ 또는 퇴사할 경우 본인이나 친권자, 신원보증인에게 일정액의 금전을 지급하도록 하는 관행이 존재하였다.¹³⁾ 이러한 시대적 배경에서 일본의 최초의 노동자 보호입법인 工場法(1911. 3. 29, 법률 제46호)이 1911년에 제정되었으나,¹⁴⁾ 제정 당시 工場法은 강제근로 금지에 관하여는 특별한 규율을 하고 있지는 않았다. 한편, 1916년 제정된 工場法施行令(1916. 8. 3, 칙령 제193호)은 제24조에서 위약금이나 손해배상액을 예정하는 계약을 하는 경우에는 지방장관의 허가를 얻도록 규정하고 있었다. 그러나 이러한 입법에도 불구하고 당시 세계적인 불황과 제2차 대전의 전시경제체제라는 상황으로 인하여 전근대적 노동관행이 근절되지는 못하였다. 이에 제2차 세계대전 패망 이후 제정된 일본국 헌법(1946. 11. 3, 헌법)은 종래 만연하고 있던 이러한 전근대적인 노동관행을 근절하고 근대적인 노사관계를 확립하기 위하여 미국헌법 수정조항 제13조를 계수하여 ‘누구든지 어떠한 노예적 구속도 받지 아니한다. 또한 범죄로 말미암은 처벌의 경우를 제외하고는 의사에 반하는 고역을 과할 수 없다’는 규정을 두었고(제18조),¹⁵⁾ 일본의 労働基準法(1947. 4. 7, 제정 법률 제49호)은 이러한 헌법규정을 구체화하여 ‘강제근로 금지의 원칙’을 명문으로 규정하였고(제5조),¹⁶⁾ 나아가 배상예정의 금지(제16조), 전차금

10) 浜村彰・唐津博・青野覚・奥田香子, 「ベーシック労働法」, 第2版, 東京: 有斐閣, 2004, 3면.

11) 土田道夫, 「労働法概説 I : 雇用関係法」, 東京: 弘文堂, 2004, 69면.

12) 浅倉むつ子・島田陽一・盛誠吾, 「労働法」, 東京: 有斐閣, 2002, 25면.

13) 外尾健一, 「労働法入門」, 第5版 補訂2版, 東京: 有斐閣, 2002, 79면.

14) 시행 당시 공장법의 전문은 <http://kjs.nagaokaut.ac.jp/mikami/STS/archives/factory_act_1911.htm> (2012. 2. 11. 방문) 참조.

15) 日本国憲法 第18条 “何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。”

상쇄금지(제17조), 강제저축 금지(제18조) 등 강제근로 금지의 원칙을 구체화하기 위한 제반 제도들을 규정하였다. 요컨대, 일본 労働基準法 제16조의 배상예정 금지 규정은 제2차 세계대전 이전에 일본에서 널리 행해지고 있던 전근대적인 강제노동의 구습을 근절하고 근대적인 노사관계를 확립하기 위하여 계약자유의 원칙에 수정을 가한 것이라고 이해되어야 할 것이다.

3. 우리나라에서의 강제근로 금지 및 위약예정 금지의 입법 경위

전술한 바와 같이 일본의 경우에는 1916년 제정된 공장법시행령에서 배상예정에 관한 규제가 최초로 도입되었으나, 이러한 공장법시행령은 일제강점기의 우리나라에서는 적용되지 않았다. 이러한 이유로 당시의 우리나라의 노동자들의 생활은 일본의 경우보다 더욱 비참하였는바, 이러한 사정은 당시의 신문 사설에도 잘 나타나 있다.¹⁷⁾

「.....종래까지 조선에서는 일본공장법에 준한 각도각색의 공장취체령(工場取締令)으로 가장 불완전하게 그것을 취체하여 오게 된 까닭에 질식할 만큼 더러운 공장에서 부녀와 소년소녀노동자에 이르기까지 일야(日夜)를 가리지 않고 이십삼시간을 노동하고 있는 것을 문견(聞見)하게 된다. 소위 근대적 시설을 가진 대공장이란 데도 흔히 ‘감옥부옥(監獄部屋)’이라는 여공기숙사를 두고 계약시간 이상의 노동을 강요하며 심하면 그 노동시간 이외의 개인행동에도 무리한 제한을 가하여 옛날의 노예 그것과 똑같이 구사(驅使)하는 예가 비일비재다.」

우리나라에서 강제근로 금지의 원칙이 입법으로 도입된 것은 제한

16) 平田秀光, 「労働法入門」, 東京: 八千代出版, 2002, 25면.

17) 동아일보 1933. 10. 29.자 제4627호 1면.

헌법을 통해서 인바, 1948. 7. 17. 시행된 대한민국 헌법(1948. 7. 17, 제정 헌법 제1호) 제9조는 “모든 국민은 신체의 자유를 가진다. 법률에 의하지 아니하고는 체포, 구금, 수색, 심문, 처벌과 강제노역을 받지 아니한다.”라고 규정하여 강제노역의 금지를 헌법상 원칙으로 도입하였다. 이를 미국연방헌법 수정조항이나 일본의 헌법규정과 비교해 보면, 법문상으로는 ‘강제노역’이라고만 규정하고 있을 뿐 ‘노예제’나 ‘노예적 구속’이라는 표현을 직접적으로 사용하고 있지는 않다. 그러나 동조가 강제노역을 금지한 취지를 고려할 때, 인신의 자유를 제한하는 노예제나 노예적 구속이 용인되지 않는다는 점은 의문이 없다. 한편 헌법사적으로는 1963. 12. 17. 시행된 대한민국헌법(1962. 12. 26, 전부개정 헌법 제6호)와 1969. 10. 21. 시행된 대한민국헌법(1969. 10. 21, 일부개정 헌법 제7호)에서는 “사인으로 부터 신체의 자유의 불법한 침해를 받은 때에도 법률이 정하는 바에 의하여 구제를 법원에 청구할 권리를 가진다.”라는 규정을 두어 신체의 자유가 사인간의 관계에서도 보호되어야 한다는 점을 명시하되, 다만 개별적 법률유보를 두고 있었다(제10조 제5항 후단).¹⁸⁾ 강제노역 금지에 관한 이러한 헌법상의 보호원칙은 근로기준법을 통하여 법제화되었는바, 1953. 8. 9. 시행된 제정 근로기준법(1953. 5. 10, 제정 법률 제286호)은 제6조에서 “사용자는 폭행, 협박, 감금 기타 정신상 또는 신체상의 자유를 부당하게 구속하는 수단으로써 근로자의 자유의사에 반하는 근로를 강요하지 못한다.”고 규정하여 강제근로의 금지를 명문화하였다. 이후 근로기준법은 30여 차례 이상 크고 작은 개정이 있었지만 위 조항은 계속 유지가 되었으며, 다만 2007. 4. 11. 시행된 근로기준법(2007. 4. 11, 전부개정 법률 제8372호)에서 조문의 위치가 제7조로 변경되었다. 위 조항은 헌법이 신체의 자유를 보장하는 취지를 근로관계의 측면에서 구체화하여 사용자에 의한 근로자의 자유의사에 반하는 노동을 금지하는 취지라고 할 것이다.¹⁹⁾ 한편 제정 근로기준법 제24조는 “사용자는 근로계약불이

18) 이러한 규정은 1972. 12. 27. 시행된 대한민국헌법(1972. 12. 27, 전부개정 헌법 제8호)에서 삭제되었다.

행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다.”라는 규정을 두었는바, 이는 일본의 労働基準法 제16조의 내용과 동일한 내용이다. 동조항은 1997. 3. 13. 시행된 근로기준법(1997. 3. 13. 제정 법률 제5309호)에서 조항의 위치가 제27조로 변경되었고, 2007. 4. 11. 시행된 근로기준법(2007. 4. 11. 전부개정 법률 제8372호)에서는 그 위치가 제20조로 다시 변경되었을 뿐 그 내용은 현재까지 동일하게 유지되고 있다. 동조항은 일본과 마찬가지로 우리나라의 공업화 초기에 널리 행해지고 있던 전근대적인 강제노동의 구습을 척결하고 근대적인 노사관계를 확립하기 위한 것으로 이해되고 있다.

4. 강제근로 금지 및 위약예정 금지의 현대적 의미

이와 같이 일본과 우리나라에서의 강제근로 금지의 원칙과 이를 구체화한 위약예정 금지 제도는 공업화 초기 일본과 우리나라에서 횡행하였던 전근대적 강제노동의 구습을 근절하기 위한 것이었다. 그런데, 오늘날 우리나라에서 이러한 전근대적인 형태의 강제근로는 그 자취를 찾아보기 어려울 정도로 근절되었다고 평가되며, 따라서 강제근로 금지 및 위약예정 금지는 당초의 입법취지를 충실하게 실현하고 있다고 평가된다.

그러나 오늘날에도 근로자의 자유의사에 반하는 근로제공을 직·간접적으로 강제하는 새로운 형태의 약정들이 체결되고 있는 것도 부정할 수 없는 현실이며, 특히 위약예정 금지와 관련하여 근로자의 의무 근로기간에 관한 새로운 형태의 약정들의 유효성이 문제되고 있다.²⁰⁾ 우리나라의 경우에도 종래 연수비 반환약정의 유효성이 문제된 사례가 다수 발견된다. 따라서 근로기준법 제7조와 제20조는 오늘날에도 여전히 실천적 의미를 갖는 조항이라고 할 것이다. 다만 이들 규정을

19) 김려수, 「신노동법」, 개정증보판, 서울: 문화각, 1967, 153면.

20) 김형배, 앞의 책, 263면.

해석 및 적용함에 있어서는 강제근로에 의한 인권침해의 가능성이 상대적으로 약화된 오늘날의 사회 상황을 고려하여 구체적 타당성이 인정될 수 있도록 유연하게 해석할 필요는 있다고 생각된다.

III. 사이닝보너스 반환약정의 유효성에 관한 검토

1. 서언

앞서 본 바와 같이 오늘날에도 위약예정 금지와 관련하여 근로자의 의무근로기간에 관한 다양한 형태의 약정들의 유효성이 문제되고 있으며, 우리나라에서도 종래 연수비 반환약정의 유효성이 문제된 사례가 다수 있었다. 그러나 사이닝보너스 반환약정의 경우에는 아직까지 판례법리가 확립되었다고 보기 어려운 상황이다. 아래에서는 먼저 (i) 근로기준법 제7조 및 제20조의 적용범위에 관한 해석론을 살펴본 후, (ii) 사이닝보너스 반환약정의 유효성이 직접적으로 다루어진 몇몇 하급심 판결들의 비교분석을 통하여 사이닝보너스 반환약정에 관한 법원의 입장을 고찰한 뒤, (iii) 이러한 논의를 기초로 사이닝보너스 반환약정의 유효성에 관한 합리적인 판단기준을 모색해 보고자 한다.

2. 근로기준법 제7조 위반의 문제

근로기준법 제7조는 “사용자는 폭행, 협박, 감금, 그 밖에 정신상 또는 신체상의 자유를 부당하게 구속하는 수단으로써 근로자의 자유의사에 어긋나는 근로를 강요하지 못한다.”고 규정하고 있는바, 이는 경제적으로 우위에 있는 사용자가 그 힘의 우위를 이용하여 근로자의 자유의사에 반하는 근로를 강요하지 못하도록 함으로써 전근대적인 노사관계를 극복하고 근로자의 인격 존중과 실현을 도모하기 위한 것이다.²¹⁾ 동조는 앞서 본 바와 같이 “누구든지 …… 법률과 적법

한 절차에 의하지 아니하고는 처벌·보안처분 또는 강제노역을 받지 아니한다.”는 대한민국 헌법(1987. 10. 29, 전부개정 헌법 제10호) 제12조 제1항 제2문 후단을 구체화한 것이다. 나아가 강제근로는 직업 선택의 자유(헌법 제15조)와 근로의 권리(헌법 제32조)에도 반한다.²²⁾

한편, 사이닝보너스 반환약정의 유효성과 관련하여서는 이러한 약정이 동법 제7조의 ‘그 밖에 정신상 또는 신체상의 자유를 부당하게 구속하는 수단’에 포섭될 수 있는지가 문제될 것인바, 사이닝보너스 반환약정이 근로자의 자발적 의사를 제한하여 간접적으로 근로를 강제하는 결과를 야기하는 경우에는 일견 ‘그 밖에 정신상 또는 신체상의 자유를 부당하게 구속하는 수단’에 포섭된다고 볼 수도 있을 것이다. 그러나 근로기준법 제107조는 동조 제7조를 위반한 행위를 한 자에 대하여 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하여, 위약예정 금지를 위반한 경우에 500만원 이하의 벌금을 규정하고 있는 것에 비하여 매우 중하게 처벌하고 있는바(제114조 제1호), 이러한 점을 고려해 보면 근로기준법 제7조의 ‘그 밖에 정신상 또는 신체상의 자유를 부당하게 구속하는 수단’은 동조가 규정하고 있는 다른 수단들인 폭행, 협박이나 감금과 행위태양의 측면에서 동가성이 인정될 수 있는 것으로 제한적으로 해석할 필요가 있다고 생각한다. 사건으로는 사이닝보너스 반환약정이 일견 근로자의 자발적 의사를 제한하는 측면이 있다고 하더라도, 이러한 약정에 관하여 근로기준법 제7조를 적용하는 것은 바람직하지 않다고 생각된다. 특히, 사이닝보너스 반환약정을 체결하였음을 이유로 근로기준법 제7조 위반죄로 사용자를 처벌하는 것은 죄형법정주의의 관점에서 분명 문제가 될 것으로 생각된다.

3. 근로기준법 제20조 위반의 문제

21) 김유성, 앞의 책, 42면.

22) 노동법실무연구회 편, 「근로기준법주해 (I)」, 서울: 박영사, 2010, 442면 [이용구 집필부분].

근로기준법 제20조는 “사용자는 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다.”고 규정하고 있는바,²³⁾ 사이닝보너스 반환약정을 동조가 규정하는 ① ‘근로계약 불이행’에 대한 ② ‘위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약’으로 볼 수 있는지가 해석상 문제된다.

1) 근로계약의 불이행

근로기준법 제20조에 따라 위약금 또는 손해배상액의 예정이 금지되는 것은 근로계약의 불이행에 관한 약정이므로 본조의 적용여부를 판단함에 있어서는 먼저 주된 계약의 법적 성질이 근로계약인지 여부를 살펴보아야 할 것이다. 따라서 주식회사의 이사에 대하여 사이닝보너스 명목으로 금원을 지급한 경우에는 당해 이사가 회사로부터 위임받은 사무 이외에 사용자의 지휘·감독 하에서 일정한 노무를 담당하는 등의 예외적인 경우를 제외하고는 근로기준법이 적용되지 않으므로, 이러한 경우에는 사이닝보너스의 지급조건으로 일정한 의무근무기간을 정하고 이를 위반하는 경우 그 전부를 반환하기로 약정하였다고 하더라도 근로기준법 위반 문제는 생기지 아니할 것이다.²⁴⁾

한편, 근로계약은 근로자가 사용자에게 근로를 제공하고 사용자는 이에 대하여 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결된 계약을 의미하므로(제2조 제1항 제4호), ‘근로계약 불이행’의 전형적인 사례는 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자가 계약기간의 만료 전에 임의로 퇴사하는 것처럼 근로자가 근로계약의 주된 급부인 노무 제공의무의 이행을 거절하는 경우라고 할 것이다. 따라서, 사이닝보너스 반환약정과 관련된 의무근무기간을 근로계약의 계약기간으로

23) 선원법 제29조도 “선박소유자는 선원근로계약의 불이행에 대한 위약금이나 손해배상액을 미리 정하는 계약을 체결하지 못한다.”라고 규정하고 있다.

24) 拙稿, “이사의 보수에 관한 연구”, 『변호사』, 제37집, 서울지방법번호사회, 2007. 1, 195면.

볼 수 있는 경우에는 이러한 의무근무기간 만료 전에 근로자가 임의로 퇴사하는 것은 근로계약의 불이행에 해당할 것이다. 그런데, 근로계약의 계약기간이란 그러한 기간이 만료되면 당사자의 별도의 의사표시가 없더라도 근로계약이 당연히 종료되는 기간을 의미하는 것인데 반하여 사이닝보너스 반환약정에 포함된 의무근무기간의 경우에는 그 기간만료로 인하여 근로계약이 당연히 종료되는 것은 아니라고 할 것이므로 이러한 의무근무기간을 근로계약의 계약기간으로 보기는 어려울 것이다. 요컨대, 사이닝보너스 반환약정에 포함된 의무근무기간은 당해 반환약정의 부관으로서 근로계약의 계약기간과는 개념상 구별된다고 할 것이다. 따라서 이러한 의무근무기간을 준수하지 않은 행위가 직접적으로 근로계약의 불이행을 구성하는 것은 아니라고 할 것이다. 그러나 앞서 본 근로기준법 제20조의 입법취지를 고려해 볼 때, 동 조항의 취지가 반드시 엄격하게 근로계약 자체의 불이행에 관한 위약금 내지 손해배상의 예정만을 금지하는 취지는 아니라고 할 것이므로 사이닝보너스 반환약정에 포함된 의무근무기간이 근로계약 자체의 조건이 아니라고 할지라도 그러한 반환약정이 근로자의 퇴직의 자유를 제한하여 근로의 계속을 강요하는 결과를 야기하는 경우에는 근로기준법 제20조의 적용을 받아야 할 것이다.

2) 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약

근로기준법 제20조 소정의 ‘위약금’ 및 ‘손해배상액을 예정’이라는 개념은 민법의 용어를 차용한 것이므로 이들 개념은 일단은 민법의 해석론에 따라 이해하여야 할 것인바, 먼저 ‘위약금’이란 채무불이행이 발생한 경우 채무자가 채권자에게 지급할 것을 미리 약정하는 금액으로서(민법 제398조 제1항), 계약위반에 대한 제재금(制裁金)의 일종이다.²⁵⁾ 위약금을 지급하기로 하는 약정은 대부분 주된 계약에 부수하여 체결되므로, 기본계약의 효력이 무효로 되는 경우에는 위약금 약정 또한 당연히 무효가 된다고 할 것이다. 한편, ‘손해배상액

25) 김형배, 「노동법」, 제21판, 서울: 박영사, 2012, 262면.

을 예정하는 계약'이란 실손해와는 관계없이 채무불이행의 경우에 배상하여야 할 손해배상액을 미리 일정한 금액으로 정하는 약정을 말한다. 이러한 손해배상액의 예정은 위약금과는 달리 불법행위에 기한 손해배상의 경우에도 가능하다. 이와 같이 위약금이 채무불이행의 경우에만 문제가 되는 것에 반하여 손해배상액의 예정은 불법행위에 의한 손해배상도 포함하기 때문에 위약금과 손해배상액의 예정의 구별은 이론상으로는 의미가 있다고 할 것이다.²⁶⁾ 한편, 근로기준법 제20조의 법문을 형식적으로 이해하는 경우에는 불법행위에 기한 손해배상의 경우에는 동조가 적용되지 않는다고 볼 여지도 있으나, 동조의 입법취지를 고려해 볼 때 불법행위에 기한 손해배상액을 예정하는 계약도 금지된다고 할 것이다.²⁷⁾ 근로기준법 제20조의 법문은 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 '계약'을 체결하지 못한다고 규정하고 있지만, 취업규칙 등에 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 취지의 조항이 있는 경우에도 본조가 적용된다고 할 것이다.

3) 위반의 효과

근로기준법 제20조는 강행규정이므로 이에 위반하여 체결한 계약은 무효가 된다. 여기서 무효가 되는 계약은 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약 자체이지 근로계약이 무효가 되는 것은 아니라고 할 것이다. 한편, 본조는 일정한 금액의 배상을 예정하는 것을 금지하는 취지이므로 사용자가 근로자의 근로계약 불이행이나 불법행위로 인하여 발생한 현실적인 손해의 배상을 청구하는 것까지 금지되는 것은 아니다. 따라서 본조에 따라 '위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약'이 무효가 된 경우라도 사용자는 채무불이행이나 불법행위의 일반원칙에 따라 근로자를 상대로 사용자가 실제로 입은

26) 片岡昇, 「労働法(2): 労働者保護法」, 第4版, 東京: 有斐閣, 1999, 133면.

27) 安技英伸·西村健一郎, 「労働法」, 第7版, 東京: 有斐閣, 2002, 85면; 横井芳弘·角田邦重·脇田滋 編, 「新現代労働法入門」, 第2版, 京都: 法律文化社, 2003, 51면; 金子征史·西谷敏 編, 「基本法コンメンタール 労働基準法」, 第4版, 東京: 日本評論社, 1999, 78면; 土田道夫, 앞의 책, 72면.

손해의 배상을 청구하거나 부당이득의 반환을 청구하는 것은 원칙적으로 가능하다고 할 것이다.

4. 사이닝보너스 반환약정에 관한 판례의 전개

1) 국내의 판례

우리나라의 경우에는 아직 사이닝보너스 반환약정의 유효성이 직접적으로 문제된 대법원 판결도 나오지 않은 상황이므로,²⁸⁾ 사이닝보너스 반환약정의 유효성에 관한 명확한 판례법리가 확립되었다고 보기는 어렵다. 다만, 우리나라의 경우에도 사이닝보너스 반환약정이 쟁점으로 다투어진 몇몇 하급심 판결들이 존재하는바, 아래에서는 이들 하급심 판결들의 비교분석을 통하여 이러한 판결들을 일관할 수 있는 공통된 해석기준이 존재하는지 검토해 보고자 한다.

(1) 수원지법 2003. 5. 13. 2002가합12355 판결

본 판결은 입사 당시 회사로부터 전속계약금 조로 금 1억 5,000만원을 지급받기로 하고 3년간 회사를 위하여 전속적으로 근무하기로 하되, 위 기간 중에 회사와 동종의 사업목적을 가진 다른 회사로 전직할 경우에는 전속계약금 전액을 회사에게 반환하기로 하는 약정을 체결한 직원이 입사 후 7개월 만에 경쟁업체로 전직한 경우 이러한 전속계약금 반환약정의 유효성이 문제된 사안에 관한 것이다. 법원은 이러한 전속계약금은 회사가 직원이 근무하는 동안 지급받게 될 근로계약상의 임금과는 별도로 지급한 금액이라는 이유로 근로기준법 제20조의 적용을 배제하고, 직원이 회사에게 전속계약금을 반환

28) 사이닝보너스 반환약정의 유효성과 관련하여 대법원 2008. 10. 23. 선고 2006다37274 판결을 언급하고 있는 문헌이 있으나(박정택, “사이닝보너스(Signing Bonus) 반환과 관련한 법적 쟁점”, 『월간 노동법률』, 제228호, 서울: 중앙경제사, 2010. 5, 76면), 위 판결의 사안은 근로계약의 체결 당시 사용자가 근로자에게 실제로 금원을 교부한 사안이 아니므로 사이닝보너스 반환약정과는 직접적인 관련은 없는 것으로 생각된다.

하여야 한다고 판단하였다.

본 판결은 사이닝보너스의 법적 성질이 근로기준법상 임금에 해당 하는지 여부를 사이닝보너스 반환약정의 유효성에 대한 일응의 판단 기준으로 삼았다는 점에서, 해외연수 등과 관련하여 일정기간동안의 의무근무기간을 정하고 그 전에 퇴직한 경우 임금과 퇴직금 등을 환수한다는 약정은 근로기준법 제20조에 위반하지만, 임금환수 등과 관계없이 연수관련 경비반환의무 면제조건으로 의무근무기간을 정하는 약정은 근로기준법 제20조에서 금지하는 위약금 또는 손해배상액의 예정 약정이 아니라는 취지의 기존의 판례법리를 참고한 것으로 생각된다.²⁹⁾

(2) 서울중앙지법 2005. 1. 25, 2004가단128716 판결

본 판결 또한 “근로계약 체결 시나 근로관계의 존속 중에 제공된 (또는 제공될) 근로에 대한 대가(임금)로서가 아니라, 근로계약 기간의 확보나 타 업체로의 이직을 막기 위한 특별한 목적 등으로 퇴직 및 이직을 제한하면서 사용자가 근로자에게 임금과는 별도로 제공하는 금원에 대하여 기간만료 전의 퇴직 및 이직 등 근로자의 특약불이행을 이유로 반환약정을 하는 것은 유효하다고 볼 수 있으나, …… 원칙적으로 그 제공되는 금원의 액수와 근로계약기간(퇴직제한 기간) 및 이직 제한의 정도가 균형을 이루어야 하고 ……”라고 판시하여 사용자가 근로자에게 임금과는 별도로 제공한 금원의 반환약정에 관하여는 원칙적으로 근로기준법 제20조가 적용되지 않는다는 입장을 취하였다. 본 판결은 이러한 점에서 위 수원지법 2003. 5. 13, 2002가합12355 판결과 유사한 입장이라고 할 것이다.

한편, 본 판결의 판시 중에 ‘원칙적으로 그 제공되는 금원의 액수와 근로계약기간(퇴직제한 기간) 및 이직 제한의 정도가 균형을 이

29) 대법원 1980. 7. 8. 선고 80다590 판결; 대법원 1992. 2. 25. 선고 91다26232 판결; 대법원 1982. 6. 22. 선고 82다카90 판결; 1996. 12. 6. 선고 95다24944, 24951 판결 등.

루어야 한다’는 부분은 이러한 반환약정이 근로기준법 제20조의 적용을 받지 않더라도, 일반론으로 돌아가 민법 제103조나 제398조 제2항에 따른 통제는 받아야 한다는 취지로 생각된다.

(3) 창원지법 2007. 11. 16, 2007나9102 판결

본 판결은 회사와 근로자들 간에 ‘임금체계변경에 따라 발생할 수도 있는 근로자들의 불이익 등에 대한 보상 및 그 동안 회사에 대한 기여도의 보상, 향후 생산성 향상을 위한 격려 등을 종합적으로 고려하여 근속연수에 따라 통상임금의 12개월분에서 41개월분까지 차등하여 회사가 근로자에게 보상금을 지급하기로 하되, 근로자가 보상금을 지급받은 날로부터 2년 이내에 회사의 의사에 반하여 사직하고자 하는 경우에는 지급받은 보상금에서 2년을 채우지 못한 기간에 해당하는 비율의 금원을 회사에 반환한다’는 취지의 노사합의서가 체결되고, 이에 따라 회사로부터 보상금을 지급받은 근로자가 보상금의 수령일 익일에 회사에 사직원을 제출한 사안에 관한 것이다. 이에 법원은 위 노사합의서는 노사간에 근로조건인 장래의 임금체계의 변경을 합의하면서 2년간 의무근무를 조건으로 보상금을 지급하는 내용으로 근무기간이 1년에 불과한 피고가 종전에 수령한 임금을 반환하는 내용이 아니고, 위 보상금을 포기하면 언제든지 근로계약에서 벗어날 수 있어 위 노사합의서 조항이 해당 직원의 직장선택의 자유나 퇴직의 자유를 제한하는 규정이라고 볼 수 없다고 하여 회사의 반환청구를 긍정하였다.

본 판결 역시 회사가 근로자에게 지급한 금원의 법적 성질이 근로기준법상 임금에 해당하는지 여부를 반환약정의 유효성에 판단기준으로 삼았다는 점에서 위 수원지법 2003. 5. 13, 2002가합12355 판결 및 서울중앙지법 2005. 1. 25, 2004가단128716 판결과 유사한 입장이라고 할 것이다.

(4) 인천지법 부천지원 2009. 4. 10, 선고 2007가합3994 판결

본 판결은 최소 5년간 근무하는 조건으로 입사한 직원이 입사 당시 회사로부터 금 5,000만 원을 지급받으면서 ‘회사의 발전을 위하여 최선을 다하고, 본 계약을 이행하지 못할 경우에는 계약금 성격의 지급금액에 대한 3배를 배상한다’는 취지의 근로사향협약서를 작성하였으나, 입사 이후 5개월 만에 퇴사하였고, 이에 회사가 위 협약서에 근거하여 직원에게 금 1억 5천만 원을 청구한 사안에 관한 것이다. 법원은 위 협약서는 직원이 약정근무기간 이전에 퇴직하는 등 위 약속을 위반하기만 하면 그로 인하여 사용자에게 어떤 손해가 어느 정도 발생하였는지를 묻지 않고, 바로 미리 정한 금 1억 5천만 원을 사용자에게 손해배상액으로 지급하기로 하는 약정이므로, 근로기준법 제20조가 금지한 전형적인 위약금 또는 손해배상액의 예정에 해당하여 그 효력을 인정할 수 없다고 판시하였다. 본 판결은 위 수원지법 2003. 5. 13, 2002가합12355 판결 등과는 달리 직원이 회사로부터 수령한 금원의 3배를 배상한다는 취지의 약정이 체결된 사안이라는 점에서 이러한 약정이 근로기준법 제20조에 위반한다는 점이 비교적 명료한 사안이라고 할 것이다. 따라서 본 판결과 위 수원지법 2003. 5. 13, 2002가합12355 판결 등은 기본적인 사실관계가 상이하므로 이들 판결들이 상호 모순된다고 볼 수는 없을 것이다.

한편, 앞서 본 바와 같이 근로기준법 제20조 위반을 이유로 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약이 무효로 된 경우에도 사용자는 채무불이행이나 불법행위의 일반원칙에 따라 근로자를 상대로 사용자가 실제로 입은 손해의 배상을 청구하거나 또는 부당이득의 반환을 청구하는 것은 가능하다고 할 것이므로, 사용자가 실제로 입은 손해 또는 손실의 배상 또는 반환을 청구하는 것이 허용되는지가 문제될 것이나, 본 판결에서 이러한 점은 쟁점이 되지 않았다. 이와 관련하여, 위 근로사향협약서상의 최소 근무기간 약정은 법적으로

효력이 없으므로 근로자의 조기 퇴사를 위법하다고 보기는 어렵다는 점에서 사용자가 근로자를 상대로 손해배상을 청구하는 것은 허용되기 어려울 것으로 생각된다. 따라서 사용자가 민법 제741조에 따라 부당이득의 반환을 청구할 수 있는지 여부만이 문제가 될 것인바, 이와 관련하여서도 사용자 스스로 강행법규인 근로기준법 제20조에 위반하여 지급한 계약금의 반환을 구하는 것은 민법 제746조 소정의 불법원인급여에 해당한다고 평가될 여지가 있다. 사건으로는 사용자가 근로기준법 제20조에 위반하여 지급한 계약금은 불법원인급여에 해당하며 따라서 근로자에게 그 반환을 청구할 수 없을 것으로 생각한다. 회사가 우수인력을 스카우트하기 위하여 사이닝보너스 제도를 설계하는 과정에서 관련법령을 간관하여 제도설계에 실패한 책임을 근로자에게 돌리는 것은 부당하다고 할 것이기 때문이다.

2) 일본의 판례

일본에서는 일본 폴라로이드 사건이 사이닝보너스 반환약정의 유효성에 관한 리딩 케이스로 주로 언급되고 있는바 그 내용은 다음과 같다.³⁰⁾

30대 남성인 A는 미국에서 MBA를 취득하고 귀국한 후, H사를 거쳐 투자 관련 벤처기업 I사의 집행임원으로 재직하고 있다가 헤드헌팅에 의하여 P사에 채용되어 2001. 7. 1.자로 P사로 이직하였다. 당시 P사가 A에게 제시한 근로조건은 ① 최초 연봉은 1,650만푼이며, 연봉의 검토는 매년 실시함, ② 사이닝보너스 200만푼은 입사 후 즉시 일괄 지급, ③ A가 1년 이내에 자발적으로 퇴직하는 경우 사이닝보너스 전액을 P사에 반환한다는 조건이었다. 그런데, A가 P사에 입사한 이후 P사의 모회사가 도산하자 A는 회사의 장래에 불안을

30) 東京地判 2003. 3. 31. 労判 849号 75頁. 이 판결에 관한 평석으로는 水町勇一郎, “中途退職者に契約締結金(サイニングボーナス)の返還を求める規定の違法性 - 日本ボラロイド(サイニングボーナス等)事件”, 「ジュリスト」, 제1266호, 2004. 4, 204~207면.

느끼고 입사 후 반년이 지난 무렵인 2001. 12. 15.에 P사를 퇴사하였다. 한편, A는 P사에 입사한 후 퇴사할 때까지 반 년 동안 합계 825만원의 급여를 받았다. 이에 P사는 A에게 사이닝보너스 200만원의 반환을 청구하는 소를 제기하였다.

이러한 P사의 청구에 대하여 동경지방법판소는 (i) 사이닝보너스의 법적 성격에 관하여 이러한 금원은 ‘일정한 기간 기업에 구속되는 것에 대하는 대가로서의 성질’도 가진다고 판단하였고, 따라서 (ii) 사이닝보너스의 반환약정은 일정한 기간의 구속을 의도한 경제적 금족책으로 근로자의 의사에 반하여 근로를 강제하는 부당한 구속수단에 해당되며, 따라서 労働基準法 제5조(강제노동의 금지)와 제16조(배상예정의 금지)에 위반하므로 무효라고 판단하였다. 이 사건에서 법원은 A가 반환을 요구받은 사이닝보너스 금액인 200만원이 A의 월급여의 2배에 상당하는 금액으로 절대적인 액수로도 적지 않은 규모라는 점, 따라서 퇴사의 경우에 이러한 규모의 금원을 반환해야 한다면 근로자는 일반적으로 퇴사를 주저하게 되는 것이 상당할 것이라는 점 등의 사정을 고려한 것으로 보인다.

5. 소결 : 사이닝보너스 반환약정의 유효성 판단기준

앞에서 살펴 본 우리나라의 하급심 판결들의 태도는 기본적으로 ‘사이닝보너스의 임금성을 인정할 수 있는지 여부’를 그 반환약정의 유효성의 일차적인 판단기준으로 삼고 있는 것으로 보인다. 사이닝보너스를 지급할 당시 근로자가 의무근무기간을 준수함을 조건으로 이를 지급하기로 약정하는 경우, 지급 당시의 시점에서는 사이닝보너스가 근로제공의 대가로 지급된 것은 아니라는 점에서 보면 하급심 판결들의 입장도 수긍할 수 있을 것이다. 아마도 이들 하급심 판결들이 사이닝보너스의 임금성을 부정한 이유는 사이닝보너스의 임금성을 부정함을 통하여 그 반환약정에 대하여 근로기준법 제20조의 적용을 배제하기 위한 것으로 생각된다. 그러나, 의무근무기간을 조

건으로 지급된 사이닝보너스는 기본적으로 ‘일정한 기간 기업에 구속되는 것에 대한 대가’로서 지급된 것이라는 점도 부정하기는 어려울 것이다. 따라서 일부 하급심 판결들과 같이 사이닝보너스를 ‘임금과는 별도로 지급한 금액’이라고 단정하여 그 임금성을 부정하는 것은 적절하지 않다고 생각한다. 참고로 조세법상으로도 사이닝보너스를 근로소득으로 취급되고 있는 것이 현재의 경향이다.

사건으로는 사이닝보너스 반환약정의 유효성은 먼저 ① 사이닝보너스를 지급하게 된 경위(예컨대, 전직을 하는 근로자가 종전의 직장에서 퇴사하는 과정에서 불가피하게 발생한 손실을 전보하기 위해 지급된 금원인지 등의 사정)와 지급약정의 제반조건(예컨대, 의무근무기간의 장단, 사이닝보너스 금액의 규모, 반환조건 등)을 종합적으로 고려하여 그 반환약정의 법적 성격이 위약금 약정 또는 손해배상액의 예정에 해당하는지를 판단하여 만일 위약금 또는 손해배상액의 예정에 해당한다면 그 반환약정 전부를 무효로 하여야 할 것이다. 구체적으로는 민법 제659조 제1항의 취지를 고려하여 3년을 넘는 장기로 의무근무기간으로 정하거나, 사용자가 지급한 사이닝보너스 금액 이상의 금원의 반환을 예정하거나, 근로자가 근로를 제공한 기간과 무관하게 사이닝보너스 전부의 반환을 예정하는 약정 등의 경우에는 금지된 위약금 약정으로 볼 가능성이 커질 것이다. 또한, 사이닝보너스가 근로자가 종전의 직장에서 퇴사하는 과정에서 불가피하게 발생한 손실을 전보하기 위해 지급되었다는 사정 등이 인정된다면 그 반환을 예정하는 것은 금지된 위약금 약정으로 보는 것이 타당할 것이다. 또한, 사이닝보너스의 금액이 비교적 다액이어서 그 반환을 요구받는 경우 근로자가 퇴사를 주저하게 될 것으로 인정되는 경우에도 그러한 반환약정이 위약금 또는 손해배상액의 예정으로 평가될 가능성이 높아질 것이다(위 일본 폴라로이드 사건). 한편 ② 사이닝보너스 반환약정이 위약금 또는 손해배상액의 예정에 해당하지 않는다면 다음으로 사이닝보너스의 ‘임금성’을 검토하여 사이닝보너스가 의무근무기간의 근로에 대한 선급임금의 성격을 갖는다면 전

체 사이닝보너스의 금액에서 근로자의 퇴사시점까지 근로자가 근로를 제공한 기간에 대한 임금조로 지급된 부분을 공제한 나머지 금액에 대해서만 반환청구를 인정하는 것이 합리적일 것이다. 사이닝보너스 반환약정에서 의무근무기간 전체에 대하여 근로자가 퇴사할 때까지 근로기간을 고려하여 그 반환금액을 비율적으로 산정하도록 약정한 경우에는 사이닝보너스를 선급된 임금이라고 보는 것이 합리적 것이며, 이러한 경우 근로자가 근로를 제공한 기간에 대한 임금에 해당하는 부분의 반환은 허용되지 않을 것이다.

IV. 맺는 말

필자는 본고에서 사이닝보너스 반환약정의 유효성과 관련하여 문제가 되는 근로기준법 제7조 및 제20조의 입법연혁과 이러한 규정들의 현대적 의미를 살펴보고, 이를 토대로 사이닝보너스 반환약정의 유효성 판단에 관한 몇 가지 기준을 제시해 보았다. 본고를 통하여 사이닝보너스와 관련된 제반 쟁점에 관한 체계적인 해석론을 제시해 보고자 하였으나, 아직 미진한 부분이 많음을 자인한다. 다만 사이닝보너스 반환약정의 유효성에 관한 논의가 거의 전무한 상황에서 본고가 사이닝보너스 반환약정의 유효성 및 더 나아가 위약예정 금지의 현대적 의미 등에 대한 논의에 관하여 주의를 환기시키고 후속연구의 참고지점으로 기능할 수 있었으면 하는 작은 바람으로 결론을 갈음하고자 한다.

- ▶ **주제어** : 사이닝보너스, 위약금, 손해배상의 예정, 강제근로 금지, 위약예정 금지

참고문헌

[국내문헌]

김려수, 「신노동법」, 개정증보판, 서울: 문화각, 1967

김유성, 「노동법 I : 개별적 근로관계법」, 서울: 법문사, 2005

김형배, 「노동법」, 제21판, 서울: 박영사, 2012

노동법실무연구회 편, 「근로기준법주해 (I)」, 서울: 박영사, 2010

_____, 「근로기준법주해 (II)」, 서울: 박영사, 2010

오승철, 「헌법이야기」, 서울: 태운당, 2011

임종률, 「노동법」, 제10판, 서울: 박영사, 2012

권오성, “이사의 보수에 관한 연구”, 「변호사」, 제37집, 서울지방변호사회, 2007.1

박정택, “사이닝보너스(Signing Bonus) 반환과 관련한 법적 쟁점”, 「월간 노동법률」, 제228호, 서울: 중앙경제사, 2010.5

[외국문헌]

金子征史・西谷敏 編, 「基本法コンメンタール 労働基準法」, 第4版, 東京: 日本評論社, 1999

- 浜村彰・唐津博・青野覚・奥田香子, 「ベーシック労働法」, 第2版, 東京: 有斐閣, 2004
- 小西國友・渡邊章・中嶋土元也, 「労働関係法」, 第3版, 東京: 有斐閣, 1999
- 安技英伸・西村健一郎, 「労働法」, 第7版, 東京: 有斐閣, 2002
- 外尾健一, 「労働法入門」, 第5版 補訂2版, 東京: 有斐閣, 2002
- 浅倉むつ子・島田陽一・盛誠吾, 「労働法」, 東京: 有斐閣, 2002
- 清正寛・菊池高志, 「労働法 エッセンシャル」, 第3版, 東京: 有斐閣, 2002
- 土田道夫, 「労働法概説 I: 雇用関係法」, 東京: 弘文堂, 2004
- 片岡昇, 「労働法(2): 労働者保護法」, 第4版, 東京: 有斐閣, 1999
- 平田秀光, 「労働法入門」, 東京: 八千代出版, 2002
- 横井芳弘・角田邦重・脇田滋 編, 「新現代労働法入門」, 第2版, 京都: 法律文化社, 2003
- 水町勇一郎, “中途退職者に契約締結金(サイニングボーナス)の返還を求める規定の違法性 — 日本ポラロイド(サイニングボーナス等)事件”, 「ジュリスト」, 제1266호, 2004.4

ABSTRACT

A study on a signing bonus

Kwon, Oh-Seong

Attorney at law,

Associate professor of Sungshin

Women's University College of Law

In Korea, since the late 1990s Companies have been offering signing bonuses which have been one way of helping them to recruit and retain employees. In case that signing bonuses are offered under some restrictions such as employees would be required to work a certain period of compulsory, the validity of the contract might be a legal issue in connection with the provision of Article 7 and 20 of the Labor Standards Act.

The provision of Article 7 of the Labor Standards Act provides that no employer shall force a worker to work against his own free will through the use of violence, intimidation, confinement or any other means which unlawfully restrict mental or physical freedom and the provision of Article 20 of the Labor Standards Act prohibits an employer and an employee from entering into a contract by which a penalty or indemnity for damage incurred from non observance of a employment contract is predetermined.

This article first addresses the origin of the principle of

prohibiting forced labor. And then, this article reviews the provision of Article 7 and 20 of the Labor Standards Act. Lastly, this article focuses on the validity of signing bonus a contract by which an employee might be required to work a certain period of compulsory.

▶ **Keywords** : signing bonus, penalty for breach of contract, liquidated damages, forced labor, prohibition of predetermination of non-observance